

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

MORALIDAD PÚBLICA / Deber funcional de todos los servidores públicos.

Visto lo anterior y contrario a lo planteado por la defensa, la Moralidad Pública no es un raciocinio abstracto ni peregrino aislado de la realidad funcional de la administración para reprochar comportamientos disciplinarios a los funcionarios públicos, que con su actuar lo transgreden, por el contrario es un principio de raigambre Constitucional referente de partida del deber funcional al que todos los servidores y funcionarios públicos se encuentran subordinados y por mandato expreso de la ley en la obligación de cumplir y hacer cumplir¹, en los términos del artículo 209 Superior,² sobre el particular, en armonía con el artículo 22 del CDU³.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLITICA- ARTICULO 209 / LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 22

VIOLACIÓN AL REGIMEN DE INHABILIDADES / Violación al deber sustancial de moralidad pública.

Así las cosas, en el sub examine aparece palmario que la ex funcionaría investigada afectó su deber funcional y por esta vía la función pública, pues al incurrir en conducta violatoria del régimen de inhabilidades, pasó por alto que su actuar funcional debe estar encaminado a la salvaguarda de la moralidad pública, transparencia, legalidad y en este caso, la conducta típica enunciada resulta sustancialmente contraria al ordenamiento jurídico vigente, en la medida en que la disciplinada, en el ejercicio de su cargo, debió actuar con apego al ordenamiento jurídico, absteniéndose de continuar ejerciendo como funcionaria pública, tan pronto surgió para ella la inhabilidad sobreviniente claramente por ella conocida, ligada a la condena penal impuesta, que al no ser advertida por la procesada a la Administración, mancilló el deber funcional de naturaleza sustancial referente a la moralidad pública.

¹ **Artículo 6 CN.** Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

² **Artículo 209 ibíd.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de Igualdad, **Moralidad**, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

³ **Artículo 22.** Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la **Moralidad Pública**, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución y en la ley.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 37

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2013-0189
Número y fecha del fallo:	00015 del dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado den segunda instancia.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), en su condición de defensor de oficio de la procesada (XXX), contra la resolución 17413-038 del 30 de octubre de 2013, por medio de la cual la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia ITRC, profiere fallo sancionatorio de primera instancia dentro del Proceso Administrativo Disciplinario No.1704-01- 2013-189.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 0985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- Los hechos investigados en la presente actuación tuvieron su origen en el Auto No.1017-131 del 20 de junio de 2013,⁴ en el cual la Subdirección Disciplinaria de la DIAN, dispuso la terminación del proceso seguido en esa dependencia por el presunto “abandono injustificado del cargo”⁵

⁴ Ver folios 260-265
⁵ Art 48 núm. 55 ley 734 de 2002

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

contra la funcionaria (XXX), concluyendo que no resultaba posible deducir responsabilidad disciplinaria a la acusada, quien no era titular legítima del cargo porque sobre ella pesaba condena penal que la inhabilitaba para el ejercicio de funciones públicas.

2.- En consecuencia se ordenó la compulsa de copias de toda la actuación a esta Agencia ITRC, para que en el marco de sus competencias, se investigue la posible comisión de la falta disciplinaria contemplada en el artículo 48, numeral 17 del CDU, con ocasión del presunto comportamiento de “actuar u omitir, a pesar de existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses”, en que habría incurrido la señora (XXX).

3.- Por lo anterior mediante auto No.17403-157 del 23 de julio de 2013⁶, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de esta agencia ITRC, dispuso apertura de indagación preliminar contra (XXX), decisión notificada por edicto del 30 de agosto de 2013⁷.

4.- Mediante resolución No.17412-017 del 9 de septiembre de 2013⁸, el despacho A-Quo calificó el mérito de las pruebas recogidas en la etapa preliminar, formulando auto de Citación a Audiencia de juicio Verbal y Cargos a la funcionaria (XXX), por la posible incursión en la falta disciplinaria Gravísima descrita en el numeral 17 del artículo 48 del CDU, referente a “actuar u omitir, a pesar de existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses”, providencia notificada mediante abogado de oficio⁹, en razón a que no se pudo llevar a cabo la notificación personal y frente a la cual presentó la defensa en términos, descargos de forma verbal y escrita en audiencia de juicio del 30 de octubre de 2013¹⁰.

5.- Una vez practicadas y valoradas las pruebas en audiencia, se dispuso correr traslado para presentar alegatos de conclusión, lo cuales una vez presentados por la defensa en la misma audiencia del 30 de octubre de 2013, se dispuso suspender la diligencia a efectos de emitir en la misma calenda el fallo de primera instancia.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

⁶ Ver folios 367-368

⁷ Ver folio 407

⁸ Ver folios 433-443

⁹ Ver folio 423

¹⁰ Ver folios 518-542

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

Mediante resolución 17413-038 del (30) treinta de octubre de 2013¹¹ el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la UAE Agencia ITRC, profirió fallo de primera instancia en el cual resumió en algunos párrafos los hechos objeto de investigación; el cargo formulado y los argumentos defensivos del procesado, planteados a lo largo del juicio verbal, como de los alegatos de conclusión. De la misma manera se resumieron valoraron y evaluaron conjuntamente la totalidad de las pruebas recaudadas a lo largo de toda la actuación.

Inmediatamente después, la primera instancia inició su exposición de motivos citando la normatividad que le atribuye competencias para fallar el sub examine. A renglón seguido nombran en el fallo impugnado los preceptos legales que describen en materia disciplinaria, la exigencia probatoria mínima para sancionar y el sistema de valoración o apreciación integral probatoria.

Consideró el fallador de primera instancia, que con base en el análisis probatorio decretado y practicado legal y oportunamente en el plenario, tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio, la imputación que se formuló a la investigada dentro de la citación a audiencia y cargos, constituye una imputación diáfana y concreta, de suerte que el disciplinado conto con todas las posibilidades procesales de ejercer sus derechos de contradicción y defensa respecto de la misma, para proceder a decidir como en derecho correspondía.

Continuando con la motivación del fallo, referente a la valoración probatoria, estimo el despacho A-Quo que se encontraba probada la materialización de la conducta típica e ilícitamente sustancial endilgada en el pliego de cargos¹² a la funcionaria (XXX), en cuanto a que de la valoración conjunta y sistemática de las pruebas allegadas legal y oportunamente al plenario, se pudo establecer en grado de certeza y más allá de toda duda razonable, que el factor determinante que dio lugar a la configuración de la conducta de “actuar u omitir a pesar de existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses”, tuvo su origen en que pese a haber sido condenada la disciplinada (XXX) a pena privativa de la libertad y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, ejerció las funciones propias del cargo que ostentaba en la Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla, durante el período comprendido del 17 de noviembre de 2010 al 14 de marzo de 2011.

¹¹ Ver folios 520-542

¹² Ver folio 433-443

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

En tal sentido considero el despacho A-Quo que la conducta endilgada a la procesada, se adecúa a la descripción típica del artículo 48 núm.17 del CDU arriba referido, toda vez que quedó demostrado en grado de certeza la inobservancia en el cumplimiento de la inhabilidad por parte de la disciplinada y sentenciada por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal¹³, lo que tuvo como consecuencia la configuración de la conducta reprochada en sede disciplinaria.

Continuando el despacho A-Quo con la motivación del fallo, argumentó el cabal cumplimiento del requisito de la ilicitud sustancial satisfecho, al expresar que la conducta imputada a la procesada vulneró su deber funcional sin justificación alguna, pues en su condición de servidora pública debía actuar bajo postulados de moralidad pública, diligencia, eficiencia, eficacia, y cuidado en sus actuaciones¹⁴, es decir a partir de normas rectoras de su ejercicio, tal como lo establece la ley disciplinaria en sus artículos 5 y 22, por cuanto, al asumir su cargo la disciplinada, se comprometió a cumplir con fidelidad cabalidad y respeto sus deberes funcionales, legales y constitucionales; situación que considero el despacho instructor que en el sub examine no se cumplió, sino que por el contrario la disciplinada mancilló los principios enunciados de la función pública a los que estaba obligada acatar, sin justificación alguna.

Con relación al requisito estructural normativo de la culpabilidad de la falta, mantuvo el fallador de primera instancia su posición esbozada en el auto de cargos, al considerar que la falta objeto de sanción debía ser imputada a título de dolo, por cuanto consideró que la funcionaria era plenamente capaz de comprender la ilicitud de su comportamiento, dada su larga trayectoria en la entidad, sobre las repercusiones legales de su actuar y el contenido de las normas que regulan la materia.

Por lo anterior concluyo el despacho a-quo que la investigada conocía la determinación que en su contra se adoptó por la autoridad penal, en el sentido de condenarla a pena privativa de la libertad y a la accesoria inhabilitación para el ejercicio de cargos y funciones públicas, porque la investigada interpuso recursos ordinarios y extraordinarios de apelación y casación respectivamente por conducto de apoderado de confianza, lo cual confirmaría su conocimiento y conciencia acerca de

¹³ Ver folio 36-74 Cno anexo 1

¹⁴ Constitución Política-Art 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de **igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad**, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

la existencia de tal decisión adversa a sus intereses, continuando en el ejercicio del cargo y absteniéndose de entregar el debido reporte de rigor al nominador, como lo exige la norma¹⁵.

En el acápite subsiguiente, titulado Contestación a los argumentos de defensa, el fallador de primer grado hizo énfasis en que no le asiste razón a la defensa, en la pretensión de justificar la conducta de la investigada, en el sentido de que su reintegro a la entidad obedeció a la decisión de la autoridad penal que la exoneró en primera instancia de responsabilidad penal y que por tanto, su ejercicio a partir de entonces era legítimo.

Indico el libelista que conforme se lee en los documentos allegados en el curso de la actuación, la señora (XXX) fue absuelta por el Juez Penal de primer grado, pero dicha decisión fue impugnada por la Fiscalía General de la Nación,alzada a propósito de cuyo trámite se emitió decisión condenatoria, como se lee en la sentencia de fecha 24 de mayo de 2010, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Penal, mediante la cual se declaró a la señora (XXX), coautora responsable de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público, cohecho y autora responsable del delito de falsedad ideológica en documento público y que dicha providencia, condenó a la investigada a la pena principal de 108.9 meses de prisión y 56.25 salarios mínimos de multa y a la pena accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo término de la pena principal.

Señalo el despacho de primer grado que al cobrar firmeza y ejecutoria la decisión condenatoria el 17 de noviembre de 2010, la señora (XXX) tenía el deber legal de reportar a la DIAN la situación jurídica en la que se encontraba, por pesar sobre ella una condena penal, de donde surge que al obviar tal obligación y mantenerse a partir de entonces en el ejercicio del cargo, lo que ocurrió hasta 14 de marzo de 2011, su desenvolvimiento funcional resultó ilegítimo por inhabilidad sobreviniente, aunado a que el actuar de la investigada fue voluntario y consciente.

En lo concerniente a la calificación de la falta, el despacho A Quo mantuvo la posición previamente asumida en el auto de cargos, en consecuencia, califico la conducta imputada disciplinariamente a la funcionaria (XXX), como Gravísimas a título de dolo, al hallarla enmarcada en los preceptos normativos del artículo 48, numeral 17 de la Ley 734 de 2002, en correlación con el artículo 13 ibídem.

¹⁵ Art 6 ley 190-1995- Art 48 núm. 17 ley 734 de 2002.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

En el proceso de dosificación de la sanción, atendiendo a la calificación concreta como Gravísima a título de dolo imputada a la disciplinada, consideró el despacho de primera instancia viable la imposición de la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de doce (12) años, teniendo en cuenta para la graduación de la sanción los criterios normativos en su favor del artículo 47 del CDU, en cuanto a su ausencia de antecedentes disciplinarios y no pertenecer a un cargo del nivel directivo o ejecutivo de la DIAN y como criterio en su contra que conocía de la ilicitud de su conducta irregular y el grave daño social de la conducta.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es con la presentación del escrito de alzada fechado el día 1 de noviembre del 2013¹⁶, el defensor de la procesada sustentó su recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio de primera instancia, solicitando de este despacho de segunda instancia, la absolución o rebaja a la mínima de la sanción de su prohijada, con base en los siguientes fundamentos:

El abogado apelante planteó que la conducta de la disciplinada no conlleva una grave afectación frente a la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado, porque en ningún momento hubo un detrimento patrimonial ni deterioro material de bienes jurídicamente protegidos, ni una afectación social por no estar bajo un supuesto de hecho que trate sobre derechos humanos.

Alego el inconforme que no se puede predicar responsabilidad disciplinaria a la investigada a partir de criterios de la moral como determinantes de la sanción. En tal sentido señalo jurisprudencia Constitucional sobre el criterio de la moral como ambiguo, más aún en el derecho sancionador donde el principio de legalidad comporta la necesidad de la tipicidad de las conductas como un análisis objetivo de los hechos.

De otra parte arguyo la defensa que el estatuto anticorrupción vigente es la ley 1474 de 2011, que deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en su artículo 135, sin mencionar nunca que complementa lo dispuesto por la ley 190 de 1995. Por lo anterior arriba a la conclusión que el

¹⁶ Ver folios 547-553.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

despacho A-Quo no podía hacer uso del artículo 6 de la ley 190 mencionada, para determinar el deber funcional reprochado.

Por otra parte agrego que no se podía predicar el dolo por una conducta realizada dentro de la ignorancia, porque no es inherente al oficio de la disciplinada conocer todas las disposiciones del derecho disciplinario, en razón a que el grado de estudios profesionales solo inciden en la sanción por imponer o en la calificación de la conducta cuando se relaciona directamente con el oficio desempeñado, entonces la conducta debía estar relacionada con el ejercicio de la profesión de economista, como lo es la profesión de la procesada, para que su nivel de estudios sirviera como elemento determinante para la sanción.

Agrego que no se puede hablar de dolo al momento de analizar el acceso de la disciplinada al cargo, por cuanto esta conto con la aprobación de la DIAN, bajo el presupuesto de la decisión judicial absolutoria de primera instancia. Por lo anterior considera que este factor no es tenido en cuenta por el A-Quo en la calificación subjetiva de la conducta y en consecuencia la sanción resulta ser desproporcionada.

En síntesis, estos fueron los planteamientos por los cuales el defensor solicitó la absolución de responsabilidad disciplinaria de su prohijada.

Por auto del 9 de diciembre del 2013¹⁷, este despacho dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del CDU, modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, corriendo traslado a los sujetos procesales, apelantes y no apelantes, por el término común de dos (2) días, para presentar alegatos finales del recurso de apelación.

Cumplida la notificación a la procesada por estado del 23 de diciembre de 2013¹⁸, así mismo en estado del 20 de diciembre de la misma anualidad al abogado defensor¹⁹ y surtido el traslado pertinente, los sujetos procesales no hicieron uso de dicha oportunidad procesal, por lo tanto se recibió nuevamente el expediente en este despacho de segundo grado, para desatar la alzada.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

¹⁷ Ver folios 559

¹⁸ Ver folio 568

¹⁹ Ver folio 561

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

Previo a dar inicio a las consideraciones de instancia, es importante precisar que de conformidad con las prerrogativas legales consagradas en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "...El recurso de apelación le otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindibles al objeto de la impugnación..." *sic*.

La segunda instancia para determinar si le asiste razón o no al recurrente, indicara cual es la situación probatoria respecto de la disciplinada (XXX), extractara de ella las conclusiones a las que allá lugar y dará respuesta específica a los planteamientos deprecados por la defensa.

Sobre el particular se tiene que la imputación disciplinaria que hiciera el despacho A-Quo a la disciplinada mediante auto de cargos del 9 de septiembre de 2013²⁰, se relacionó con la posible incursión en la falta disciplinaria Gravísima descrita en el numeral 17 del artículo 48 del CDU, referente a "actuar u omitir, a pesar de existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses", por cuanto la disciplinada no dio informe oportuno a su nominador- Dian, de la inhabilidad sentenciada en su contra por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal²¹, consistente en pena principal de 108.9 meses de prisión y 56.25 SMLMV y accesoria de Inhabilidad para el ejercicio cargos y funciones públicas por el mismo término, condena la cual cobro firmeza y ejecutoria el 17 día de noviembre de 2010, con la decisión del recurso extraordinario de casación denegado por la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia.²²

Lo anterior tuvo como consecuencia la configuración de la conducta reprochada en sede disciplinaria, de acuerdo con lo establecido en el Art 6 de la ley 190-1995, el cual establece que "En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio", en concordancia con el artículo 48 numeral 17 del CDU²³.

A la anterior imputación arribo el despacho A Quo, con base en el siguiente acervo probatorio.

²⁰ Ver folio 433 y ss.

²¹ Ver folios 36-74 Cno 1.

²² Ver folios 75-110 Cno 1.

²³ Art 48 CDU Son faltas gravísimas: num.17: "actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses"...

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

Resolución No.011422 del 31 de octubre de 2011²⁴ por medio de la cual el Director General de la DIAN, declaró a partir del 14 de marzo de 2011, vacante por abandono, el cargo de Inspector II Código 306 Grado 06, del que era titular la señora (XXX).

Certificado de antecedentes disciplinarios del 5 de junio de 2012 de (XXX), expedido por la Procuraduría General de la Nación²⁵, donde registra las siguientes anotaciones:

Pena principal de prisión de 109 meses, multa de 56.25 SMLMV, y pena accesoria de Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 109 meses, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, concierto para delinquir, cohecho propio, Inhabilidad para contratar con el Estado: inicio 24/05/2010, final: 23/05/2015, Inhabilidad para desempeñar cargos públicos: inicio 24/05/2010, final: 23/05/2020²⁶.

Extracto de historia laboral de la señora (XXX), la cual indica que mediante Resolución No. 011723 del 28 de octubre de 2009, se ubica en el Despacho de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, con acta de posesión No. 0925 del 4 de noviembre de 2009²⁷.

Sentencia del 1 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, expediente No. 2008-043-00, por medio del cual se absuelve a la señora (XXX) de los hechos y cargos de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y falsedad material en documento público, formulados por la Fiscalía General de la Nación²⁸.

Oficio No. DNI-GSIC3119 del 23 de agosto de 2012²⁹ por medio del cual la Coordinadora del Centro de Atención e Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, informa que la señora (XXX), identificada con la C.C 45.437.488 de Cartagena, realizó una rectificación de nombres y apellidos el día 20 de noviembre de 2009, con nombre anterior (XXX) y nombre nuevo (XXX).

Sentencia de fecha 24 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante la cual revoca la sentencia apelada y declara a la señora (XXX),

²⁴ Ver folios 4 y 5 Cno 1

²⁵ Ver folio 412 Cno 3

²⁶ Ver folio 412

²⁷ Ver folio 14-15

²⁸ Ver folios 20-22 Cno 1

²⁹ Ver folio 82

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

coautora responsable de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y cohecho, y autora del delito de falsedad ideológica en documento público³⁰.

Auto Inadmisorio del recurso extraordinario de Casación No.35244, proferida por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal del 17 de noviembre de 2010, por incumplimiento a exigencias de fundamentación requeridas para la admisión del recurso³¹.

Planilla de asistencia de la funcionaria (XXX) al Despacho de la Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla, durante los meses de diciembre de 2010 a marzo de 2011³².

Oficio No.100206214 del 28 de octubre de 2013, por medio del cual la Subdirectora de Gestión de Personal de la DIAN, certifica las funciones desempeñadas por la investigada entre el período comprendido del 17 de noviembre de 2010 al 14 de marzo de 2011³³.

Si hasta este momento se analiza y valora de manera conjunta y sistemática en el contexto factico acreditado en el proceso, la situación probatoria de (XXX), es evidente y claramente indicativo que concurren múltiples hechos que la comprometen en la conducta acusada y posteriormente sancionada en la secuencia procesal que da cuenta el expediente.

En efecto, que una funcionaria pública no dé cuenta a su nominador de su situación jurídica claramente debatida en sede Judicial y conocida por la penada, denota una conducta que debe ser reprochada por la Administración, pues claramente trasciende la esfera de lo personal para invadir el ámbito institucional, contrario a lo alegado por la defensa, en cuanto a que no existe prueba del dolo del actuar de la disciplinada; por el contrario si se observa que es ella misma la que otorga facultades a su apoderada de confianza para que de una forma diligente y constante este impugnando y agotando todas las instancias procesales ordinarias como extraordinarias en el proceso penal seguido en su contra, como para aseverar que la funcionaria no sabía de su sanción, ni de su deber legal y apenas lógico de dar aviso a la Dian de tal situación, pues no solo debía hacerlo conforme se lo indicaba el artículo 6 de la ley 190 de 1995, estatuto anticorrupción vigente para la época de los hechos, sino que con todo la procesada decide guardar silencio sobre su nueva situación jurídica permaneciendo ilegítimamente en el cargo que ya le estaba prohibido ocupar

³⁰ Ver folio 36-74

³¹ Ver folio 75-109

³² Ver folio 458-510

³³ Ver folio 515-516

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

según la pena impuesta por el Tribunal Penal de inhabilidad, desde el 17 de noviembre de 2010 y permaneciendo en el cargo según se observa hasta el 14 de marzo de 2011.

Por lo anterior no prospera el cargo de que el despacho A-Quo no podía hacer uso del artículo 6 de la ley 190 de 1995, para determinar el deber funcional reprochado, pues como se dijo esta era la norma anticorrupción vigente para la época de los hechos.

En cuanto al alegato de que no se puede predicar responsabilidad disciplinaria de la investigada a partir del criterio de la moral pública, debe decirse al respecto que si en principio la entidad hubiera tenido conocimiento de la inhabilidad sobreviniente que recaía en la señora (XXX), por otro medio distinto a la información que esta como funcionaria pública legalmente estaba obligada a suministrarle, hubiera tenido la obligación de disponer de forma inmediata de su retiro de la entidad, pues lo cierto es que la jurisprudencia Constitucional³⁴ ha previsto que las inhabilidades impuestas por la Constitución y la ley, buscan proteger derechos colectivos y asegurar la Moralidad Pública como principio regente Constitucional y legal del Estado Social de Derecho y sobre el cual deben formar parte del Estado personas sobre las cuales no recaigan tachas sobre su idoneidad y probidad³⁵.

Visto lo anterior y contrario a lo planteado por la defensa, la Moralidad Pública no es un raciocinio abstracto ni peregrino aislado de la realidad funcional de la administración para reprochar comportamientos disciplinarios a los funcionarios públicos, que con su actuar lo transgreden, por el contrario es un principio de raigambre Constitucional referente de partida del deber funcional al que todos los servidores y funcionarios públicos se encuentran subordinados y por mandato

³⁴ **Sentencia T-887/05:** En efecto, la inhabilidad sobreviniente derivada de la sanción impuesta por la Procuraduría General al ciudadano tuvo lugar con ocasión de las irregularidades advertidas en el trámite contractual(...) Estas conductas, a juicio de las entidades demandadas, constituyeron falta disciplinaria debido a que resultaban contrarias a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público, finalidades que, como se indicó, tienen pleno reconocimiento Constitucional y en consecuencia, constituyen excepciones legítimas al desempeño en el cargo.

³⁵ Causales De Inhabilidad Fijadas Por El Constituyente-Principios en que se sustenta la prohibición de modificación de dichas causales Para esta Corte, la prohibición de modificación de las causales de inhabilidad directamente señaladas por el constituyente es consecuencia de varios principios constitucionales: i) el legislador no puede alterar las inhabilidades directamente fijadas por el constituyente porque las inhabilidades implican la limitación de un derecho fundamental y, por tanto, deben aplicarse de manera taxativa y restringida; ii) la supremacía normativa de la Constitución impide que el legislador transforme una inhabilidad directamente fijada por el constituyente; iii) si el constituyente previó una inhabilidad concreta, es porque se reservó la prerrogativa de limitar, en las condiciones por él indicadas, la restricción de acceso a ese cargo público. Esta reserva impide que otra norma modifique los alcances específicos de esa inhabilidad.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

expreso de la ley en la obligación de cumplir y hacer cumplir³⁶, en los términos del artículo 209 Superior,³⁷ sobre el particular, en armonía con el artículo 22 del CDU³⁸.

Referente a la violación de los principios Constitucionales y legales que rigen la función pública; ha dicho la H. Corte Constitucional³⁹:

"...En pos de que la función pública cumpla su objetivo, la misma Constitución Política se encargó de estipular expresamente en su artículo 209 unos principios a los cuales debe sujetarse el ejercicio de toda la actividad administrativa, si bien, dicha norma hace referencia específica a la función administrativa y la ubica dentro del capítulo concerniente a la rama ejecutiva, es pertinente señalar que dichas directrices orientan toda la actividad de Estado, razón por la cual en caso de no ser cumplidos dan lugar inequívocamente a la realización de un correspondiente control disciplinario, de allí que garantizar la aplicación de los mismos sea una de las prioridades de la potestad disciplinaria..."

Se trata entonces que en efecto estamos en presencia de un desconocimiento flagrante al régimen de inhabilidades previsto en el ordenamiento jurídico Constitucional y disciplinario, lo que se traduce en la transgresión de los principios de moralidad pública y eficacia, tal como en efecto lo plantea el fallo de primer grado.

Al respecto la jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado han precisado:

*"... Él Estado Social de Derecho debe prestar sus servicios públicos a las personas con el máximo de eficacia y **moralidad**. En este sentido, los principios de **moralidad** y eficacia, predicados en el artículo 209 de la Constitución para la gestión administrativa, son por su contenido esencial extensibles a toda la actividad estatal, en virtud de los artículos 10 y 2° Superiores⁴⁰..."*

³⁶ **Artículo 6 CN.** Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

³⁷ **Artículo 209 ibíd.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de Igualdad, **Moralidad**, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

³⁸ **Artículo 22.** Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la **Moralidad Pública**, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución y en la ley.

³⁹ Sentencia C-028 de 2006.

⁴⁰ Sentencia C-155 de 2002. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

Así las cosas, en el sub examine aparece palmario que la ex funcionaria investigada afectó su deber funcional y por esta vía la función pública, pues al incurrir en conducta violatoria del régimen de inhabilidades, pasó por alto que su actuar funcional debe estar encaminado a la salvaguarda de la moralidad pública, transparencia, legalidad y en este caso, la conducta típica enunciada resulta sustancialmente contraria al ordenamiento jurídico vigente, en la medida en que la disciplinada, en el ejercicio de su cargo, debió actuar con apego al ordenamiento jurídico, absteniéndose de continuar ejerciendo como funcionaria pública, tan pronto surgió para ella la inhabilidad sobreviniente claramente por ella conocida, ligada a la condena penal impuesta, que al no ser advertida por la procesada a la Administración, mancilló el deber funcional de naturaleza sustancial referente a la moralidad pública.

Por lo anterior no encuentra subvención de prosperidad el alegato de que no se puede predicar responsabilidad disciplinaria de la investigada a partir del criterio de la moral pública como criterio determinante en la sanción.

En cuanto al argumento planteado por la defensa de que no se podía predicar el dolo por una conducta realizada dentro de la ignorancia, porque no es inherente al oficio de la disciplinada conocer todas las disposiciones del derecho disciplinario, en razón a que el grado de estudios profesionales de esta eran de economista, con especialización en función pública.

A este respecto debe decir el despacho que si en gracia de discusión podría anotarse que la disciplinada no sabía que existía una norma que le generaba inhabilidad por el hecho de haber sido condenada penalmente, dicho razonamiento para este sensor de instancia no tiene cabida, de una parte, porque nuestro ordenamiento jurídico establece que "la ignorancia de la Ley no sirve de excusa"⁴¹, y de otra, porque es del dominio común de las personas, saber que quien es condenado a pena privativa de la libertad, también lo es a sus derechos políticos, contando además que la sentencia penal, para los fines propios de la reinserción a la vida en sociedad de la enjuiciada,

⁴¹ **Sentencia C-651/97** Deber General de Obediencia del Derecho, la Ignorancia de la Ley No Sirve de Excusa-Constitucionalidad. (...) Puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista especializado en una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento cabal de las que constituyen el área de su especialidad. Mucho menos puede esperarse que un ciudadano corriente conozca todas las normas que se refieren a su conducta. El recurso epistémico utilizado por el legislador es más bien la ficción, de uso frecuente y obligado en el derecho, y que en el caso específico que ocupa a la Corte puede expresarse de este modo: es necesario exigir de cada uno de los miembros de la comunidad que se comporte como si conociera las leyes que tienen que ver con su conducta. La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno, pues si así ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de la convivencia comunitaria, se sustituiría la anarquía que la imposibilita. La solidaridad social, un hecho inevitable que la Constitución reconoce para construir sobre él conductas socialmente exigibles, ligada al artículo 13, invocado por los demandantes como norma violada por el artículo cuestionado, sirve más bien de fundamento al imperativo que él contiene, así como el Artículo 95 que establece de modo terminante: "Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes", constituyen sólido fundamento de la disposición acusada que, por los motivos consignados, debe ser declarada conforme a la Constitución(...).

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

le impuso una inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el lapso de 108.9 meses, contados a partir de la fecha de ejecución de la sanción.

Por lo anterior el alegato de que la disciplinada no sabía de su deber legal reprochado, no está llamado a prosperar.

Ahora en cuanto al planteamiento que hace la defensa referente a que la conducta de la disciplinada no conlleva una grave afectación de trascendencia social de la falta o el perjuicio causado, porque en ningún momento hubo un detrimento patrimonial ni deterioro material de bienes jurídicamente protegidos, encuentra este despacho que en tal sentido se pronunció el despacho A-Quo sobre el particular al expresar: *"Finalmente, considerando que se advirtió que el comportamiento estudiado y sancionado, no produjo perjuicio de carácter patrimonial al Estado, quien aquí se pronuncia estima, en acatamiento del principio de proporcionalidad, que debe imponerse a la investigada (XXX) sanción disciplinaria"(...)sic.*

Frente a este tópico o criterio de graduación de la sanción a la disciplinada (XXX) en los términos del artículo 47 del CDU determinado por el despacho A-Quo, encuentra este sensor de instancia que en virtud de la ausencia probatoria que sustente el alegato de que el despacho A-Quo no lo tuvo en cuenta para sancionar, bien poco tiene que decir sobre el particular este sensor de instancia, puesto que a la hora de cimentar tal censura el recurrente, la margino de análisis fundado en pruebas legal y oportunamente allegadas al plenario, dejando el reproche meramente en el plano enunciativo, lo que no ocurre como se observa de la valoración favorable a la disciplinada que en tal sentido realiza el despacho A-Quo.

Sobre el particular se observa que la conclusión sobre el criterio de graduación de la falta que realiza el despacho de primer grado referente al *"grave daño social de la conducta"*, consagrada en el Literal g del artículo 47 Ley 734 de 2002", lo hace con base en el criterio de la "afectación a la confianza de los administrados en la función pública y en los agentes que la ejercen", por parte de la disciplinada con la conducta reprochada y no con base en los criterios expuestos por el recurrente como se examinó en precedencia, por lo tanto no hay lugar a la prosperidad del cargo alegado.

Por consiguiente, la Segunda Instancia comparte la calificación de la falta efectuada por el despacho A Quo tanto en el auto de cargos como en el fallo de primera instancia como gravísima

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

conforme al numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, referente a “Actuar u omitir, a pesar de existencia de causales de inhabilidad incompatibilidad y conflicto de intereses”, a título de dolo.

De la exposición de motivos del fallo atacado, hay que destacar que el investigador disciplinario disponía al momento de valorar las pruebas y los hechos, de un amplio campo y autonomía legal para determinar si la conducta investigada se subsumía o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si esta fue cometida con dolo o con culpa, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, con base en los criterios señalados en los Art. 13 y 43 del CDU, sin embargo el hecho de que tal valoración no beneficie al recurrente, en nada tiene que ver con violaciones al debido proceso.

Frente a la valoración probatoria ha puntualizado el H. Consejo de Estado:

(...) Vale la pena precisar que en el ámbito de los procesos disciplinarios no existe una tarifa legal probatoria; de hecho el propio Código Disciplinario Único consagra, en su artículo 131, el principio de libertad probatoria, al establecer que “la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. De manera que no es aceptable exigir que se haya recaudado un tipo determinado de pruebas –por ejemplo un testimonio o un documento- para efectos de sustentar un fallo disciplinario, que puede estar basado, por decisión expresa del Legislador, en cualquiera de los medios probatorios admitidos por el sistema legal Colombiano e incluso en otros medios probatorios, como se deduce del mismo artículo 130 ibídem⁴² (...).

En ese orden de ideas, para la segunda instancia, el criterio de interpretación, valoración y aplicación normativa y probatoria que realizó el despacho A-quo, como órgano de control disciplinario de primera instancia, al que la ley le ha dotado de amplia autonomía e independencia, se ajustó con plena subvención al ordenamiento jurídico, la sanción se impuso sin menoscabo del derecho al debido proceso de la disciplinada (XXX), luego de hallar plenamente acreditadas: la comisión de la falta gravísima (art. 48 núm. 17 CDU), la ilicitud sustancial de la conducta, (art 5º y 22 CDU) y la responsabilidad subjetiva de la actora (Art 13 CDU), con pruebas legalmente practicadas y debidamente valoradas, (Art 128 y 130 CDU), como arriba se expuso con suficiencia.

⁴²Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001032500020110012100 (041311).

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

Basten hasta aquí las consideraciones ut supra, para rechazar los argumentos de sustentación de la apelación, presentados por la defensa. Solo resta afirmar, haciendo eco del análisis probatorio realizado por el operador disciplinario de primer grado, que la expedientada (XXX), incurrió en la falta disciplinaria objeto de censura, razón por la cual deberá responder disciplinariamente por dicho comportamiento, tal como se expresará en la parte resolutive de esta providencia, al confirmar en su totalidad el fallo objeto de alzada.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el defensor de oficio Doctor (XXX), en representación de la procesada (XXX), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. En consecuencia, **CONFIRMARE EN SU TOTALIDAD** el fallo sancionatorio proferido por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la UAE Agencia ITRC mediante resolución No. 17413-038 del 30 de octubre de 2013.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101, 104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-189.

SEPTIMO: REMITIR copia de la presente decisión al nominador del procesado, para que proceda a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y parágrafo del artículo 172 de la ley 734 de 2002.

OCTAVO. Ejecutoriada esta decisión y libradas las comunicaciones de rigor, ARCHIVAR el expediente.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Julian Andres Garcia Novoa
Aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.